

<제1장 행정소송의 일반론.제3절 행정소송의 한계>

I. 사법 본질적 한계

- 행정소송은 본질적으로 사법 작용의 일환이므로, 법원의 사법적 심사 기능이 가질 수밖에 없는 일반적인 한계를 가지게 된다. 이는 법원이 국민의 구체적인 분쟁 해결 기관으로서 추상적인 법규 제정 또는 정책 집행 기관이 아니라는 사법의 특성에서 기인한다.

1. 구체적 사건성에 따른 한계

- 행정소송을 포함한 모든 사법 절차는 구체적인 사건에 대한 법적 판단을 목표로 한다. 이러한 특성은 다음과 같은 한계를 초래한다.

(1) 일반·추상적 법규에 대한 한계

- 법원은 일반적이고 추상적인 법률 또는 행정 입법 자체의 위법성을 직접적으로 다루거나 취소할 수 없다. 행정소송법상 항고소송의 대상은 처분등 구체적인 법 집행 행위로 한정되기 때문이다. 국민의 권리 의무에 직접적인 영향을 미치는 법규 명령이라 할지라도, 그것이 구체적인 집행 행위(처분)의 형태를 띠지 않는 이상, 항고소송의 대상이 되지 않는다. 다만, 판례는 구체적인 사건에 적용되는 법규 명령의 위헌·위법성을 해당 처분에 대한 소송 심리 과정에서 간접적으로 심사할 수 있다고 본다. 이를 규범 통제라 하며, 이는 법원이 처분의 위법성 판단의 전제로서 법규 명령의 위법성을 확인하는 것이다.

(2) 사실적 행위에 대한 한계

- 단순한 사실적 행위는 법적 효과를 수반하지 않기 때문에 원칙적으로 행정소송의 대상인 처분으로 인정되지 않는다. 예를 들어 행정기관의 단순한 조언이나 행정 지도 등은 법적 구속력이 없으므로 소송 대상이 될 수 없다. 그러나, 최근에는 권력적 사실 행위의 경우 국민의 권리 침해 가능성이 높으므로, 그것이 실질적으로 국민의 권리 의무에 영향을 미친다면 처분성을 인정하여 항고소송의 대상으로 보는 경향도 일부 나타나고 있다. 이러한 경향은 권리 구제 범위를 확대하려는 노력의 일환이다.

(3) 사법심사의 대상이 되지 않는 사항

- 법원의 심사 기능 자체가 미치지 못하는 영역이 있는데, 이를 사법 심사 불가능 영역이라고 한다. 예를 들어 통치 행위가 대표적이다. 통치 행위는 국가 기관의 고도의 정치적 결단을 필요로 하는 행위로서, 사법적 심사 기준이 마땅치 않거나 심사하는 것이 권력 분립 원칙상 바람직하지 않다고 판단되는 행위를 말한다. 대통령의 계엄 선포나 외교 행위 등이 논의의 대상이 되는데, 판례는 행위의 성격 및 그것이 국민의 기본권에 미치는 영향 등을 종합적으로 고려하여 사법심사 여부를 결정한다.

2. 법 적용상 한계

- 법원은 법률 문제를 다루는 기관이지 정책 또는 전문적 사실 판단을 직접 대신하는 기관이 아니다. 이러한 법원의 법 적용상의 한계는 행정작용의 재량성 영역에서 두드러진다.

(1) 재량행위의 한계

- 행정기관이 법률에 따라 자유로운 판단을 내릴 수 있는 재량행위에 대해서는, 법원은 행정기관의 판단 자체를 자신들의 판단으로 대체할 수 없다. 법원은 오직 재량권의 일탈 또는 남용 여부만을 심사할 수 있다. 재량권의 일탈 또는 남용이란 행정기관이 재량권의 한계를 넘어서 행위하거나, 재량권 내에서 행위했다라도 그 목적이 정당하지 않거나, 비례 원칙 등 일반적인 법 원칙에 위반되는 것을 의미한다. 이러한 심사 한계는 행정의 전문성 및 정책적 판단의 존중이라는 권력 분립적 요청에 기반한다.

(2) 판단 여지 영역의 한계

- 행정기관에게 법률이 전문적 또는 기술적인 사항에 대해 광범위한 사실 인정 및 평가권(판단 여지)을 부여한 경우, 법원의 심사는 더욱 제한된다. 예를 들어 공무원의 징계 양정, 시험의 합격 여부 판단, 환경 영향 평가 등 고도의 전문성이 요구되는 영역이다. 법원은 판단 여지가 부여된 영역에 대해서는 사실 오인 여부, 비례 원칙 위반 여부 등 행정기관의 판단 과정에 하자가 있는지 여부만을 심사하며, 행정기관의 판단을 대체하는 실질적인 판단은 하지 않는다. 이는 사법기관이 행정기관의 전문성을 존중하고 권한 범위를 지키기 위한 사법 자체의 원칙에서 비롯된다.

II. 권력 분립적 한계

- 행정소송은 행정권을 통제하는 기능을 수행하지만, 헌법상 권력 분립 원칙에 따라 법원이 행정권의 고유한 영역을 침범할 수 없다는 근본적인 한계를 가진다. 특히, 행정기관이 아무런 행위를 하지 않거나 장래에 위법한 행위를 할 우려가 있을 때, 법원이 적극적으로 개입하여 행정기관의 행위를 명령하거나 금지할 수 있는지 여부가 주요한 문제가 된다.

1. 의무이행소송

- 의무이행소송은 행정청이 국민에 대하여 특정한 작위(처분)를 할 의무가 있음에도 불구하고 이를 이행하지 않을 때, 법원이 직접 행정기관에게 그 처분 또는 행위를 하도록 명령하는 소송 형식을 말한다.

(1) 현행법상 의무이행소송의 부정

- 우리나라 현행 행정소송법은 의무이행소송을 명시적으로 인정하고 있지 않다. 이는 법원이 행정기관의 적극적인 행위를 명령하는 것이 행정권의 고유한 판단 영역을 침해하고 권력 분립 원칙에 위배될 수 있다는 권력 분립적 한계 때문이다. 행정청의 거부 처분이나 부작위가 있을 때, 현행법상 국민은 부작위위법확인소송이나 거부 처분 취소소송을 제기하여 승소 판결을 받을 수 있으며, 법원은 기속력에 따라 행정기관에게 재처분 의무만을 부과할 뿐, 직접 어떤 처분을 하라고 명령하지는 않는다.

(2) 학설 및 입법론상의 논의

- 그러나 국민의 권리 구제를 실효성 있게 확보하기 위해서는 의무이행소송의 도입이 필요하다는 주장이 지속적으로 제기된다. 취소판결만으로는 행정기관이 또다시 다른 사유를 들어 거부 처분을 반복할 수 있기 때문이다. 판례 역시 재량권이 없거나 기속행위의 경우 등 예외적인 상황에서는 사실상 특정한 처분 의무를 인정하는 경향이 있으나, 법적으로 의무이행소송 자체를 인정하는 것은 여전히 신중한 태도를 보인다.

2. 예방적 금지소송(예방적 부작위청구소송)

- 예방적 금지소송은 장래에 행정기관의 위법한 처분 등 공권력 행사로 인하여 회복하기 어려운 손해를 입을 우려가 있을 때, 미리 법원에 그 행위의 금지를 청구하는 소송 형식을 말한다.

(1) 현행법상 원칙적 부정

- 우리나라 행정소송법은 예방적 금지소송을 명시적으로 규정하고 있지 않으며, 학설과 판례는 원칙적으로 이를 부정한다. 그 주된 이유는 미래의 처분을 대상으로 법원이 미리 판단하는 것이 행정기관의 장래 권한 행사를 과도하게 제약하여 권력 분립 원칙에 위배될 수 있다는 점이다. 또한, 법원의 사법 심사는 구체적 사건에 국한되어야 하는데, 장래의 처분은 아직 현실화되지 않은 추상적인 문제일 수 있다는 사법 본질적 한계도 작용한다.

(2) 예외적 긍정 논의

- 다만, 예외적으로 행정기관이 장래에 위법한 처분을 할 것이 거의 확실시되며, 그 처분이 이루어진 후에 취소소송을 제기하더라도 회복하기 현저히 곤란한 손해가 발생할 우려가 있는 경우에는, 권리 구제 측면에서 예방적 금지소송의 필요성이 제기된다. 판례는 일부 사안에서 민사소송법상의 가처분 등 민사적 구제 수단을 제한적으로 인정하거나, 무명 항고소송의 일환으로 예방적 금지소송의 가능성을 논의하기도 하였으나, 현행 법제 하에서는 여전히 이러한 소송 형식의 인정에는 매우 엄격한 기준을 적용하고 있다.

Ⅳ. 결론

- 행정소송의 한계는 사법의 본질에서 비롯되는 구체적 사건성 및 법 적용상의 제한과 행정권과의 권력 분립 원칙에서 비롯되는 제한으로 나눌 수 있다. 사법 본질적 한계는 일반 법규나 사실 행위 등 처분이 아닌 사항에 대한 직접적인 심사 금지 및 재량행위와 판단 여지 영역에 대한 심사 자제로 나타난다. 권력 분립적 한계는 법원이 행정기관의 적극적인 행위를 명령하는 의무이행소송과 장래의 행위를 미리 금지하는 예방적 금지소송을 현행법상 원칙적으로 부정하는 형태로 구체화된다. 이러한 한계는 행정소송의 존재 이유인 권리 구제 및 행정 통제 기능을 유지하면서도, 사법권 남용을 방지하고 행정의 전문성과 정책 집행권을 존중하기 위한 불가피한 제한이라 할 수 있다.